

1501050-54.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... qualquer ato de associação para o tráfico, inexistindo nexo de causalidade entre a acusação e sua pessoa. Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça já decidiu: TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO. Tráfico de Entorpecentes - Materialidade do crime e autoria delitiva - Prova insuficiente - Absolvição - Recurso improvido. Diante da insuficiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501050-54.2022.8.26.0571 - Controle 2022/001247

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA SALES e outros

Data da Audiência:

18/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, dos Defensores, o advogado Vítor de Camargo Holtz Moraes, OAB 134223/SP, o advogado Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, OAB 356869/SP e dos Acusados Rodrigo Pereira Sales, Francisco Erisvan Pereira Gonçalves, Rafael Pereira Sales e Daniel Feliciano da Silva. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente os Defensores e seus representados para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunha Jonathan de Oliveira Lima arrolada pelas partes e as testemunhas Emerson Paulo Benedito Aparecido de Meira, Leandro Ribeiro Ramos e Paloma Aparecida de Meira arroladas pela defesa de Daniel. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha João Carlos Saraiva da Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acham-se processados os acusados como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal é procedente. De início, a materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência dos crimes, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Com efeito, ouvidos em solo policial e sob o pálio do contraditório, os policiais militares responsáveis pela

prisão dos acusados narraram toda dinâmica dos fatos. Afirmaram que ao surpreenderem usuários de drogas nas adjacências do imóvel em que presos os acusados, puderam observar que um indivíduo, ao notar a presença da viatura, ingressou na casa advertindo que a polícia estaria ali, pelo que foram ao seu encalço no interior da casa, onde se depararam com os demais acusados à mesa da cozinha, onde havia aparentemente o preparo de porções individuais de cocaína, com material próprio para tanto, como esmaltados vazios e já com cocaína. Salientaram, ademais, que um dos agentes, Rodrigo, tão logo notou o ingresso dos policiais no imóvel já se dirigiu até um outro cômodo, que depois se constatou que era o banheiro da casa, onde teria dispensado uma porção grande de cocaína, tendo restado vestígios disso no vaso, sendo certo que ainda puderam localizar e apreender, a par das porções de cocaína, uma grande porção de crack, maconha, balanças, esmaltados, embalagens plásticas vazias, R\$ 441,00 em dinheiro, dois celulares e um caderno com anotações típicas do tráfico. A casa, segundo informado, era de Rafael. Diante disso, deram voz de prisão aos acusados, e apreenderam a adolescente infratora que estava entre os agentes, Jeniffer, também inserida na atividade criminosa. As palavras dos policiais militares revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar as criminosas. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus. O acusado Rafael, interrogado em juízo, confessou que as drogas lhe pertenciam e se destinavam ao tráfico. Tentou, contudo, eximir os demais réus da responsabilidade, aduzindo que Francisco foi até o imóvel para outra finalidade, de carona com Daniel, e Rodrigo estaria lá para ver um motor de arranque para o trator e estava apenas conversando no local. Esta versão foi reafirmada, em parte, pelos demais réus, porém visa unicamente o afastamento da responsabilidade pelo delito de associação, porém são rechaçadas pelo próprio cenário dos acontecimentos, em especial o fato apontado pelos policiais que foi Rodrigo quem foi até o banheiro para se desvencilhar de parte da droga no vaso sanitário. Não bastasse isso, também foi apontado que Daniel é que viu os policiais e voltou para interior do imóvel avisando os demais, o que revela a preocupação com o desbaratamento da associação para o tráfico, de modo que suas palavras no sentido de que teria apenas se dirigido até para comprar entorpecentes destinados ao seu próprio uso não merece credibilidade. Em que pese, portanto, essas narrativas apresentadas, analisadas as circunstâncias envolvidas do fato penal sub examen, emerge clara a responsabilidade pela prévia associação dos acusados na prática do tráfico, inclusive com apoio da adolescente infratora, pois estavam todos atuando de maneira conjugada, no interior do imóvel, no preparo de drogas das mais diversas naturezas, como maconha, cocaína e crack, além de outros objetos próprios ao preparo e embalo de drogas. O argumento no sentido dos réus no sentido de que estariam no local por mero acaso, em razão de outros fatos que não o envolvimento com drogas, não convence, na medida em que não é minimamente idônea, dado o próprio quadro revelado, em que havia variados entorpecentes expostos à mesa. De mais a mais, esse referido cenário em que surpreendidos os agentes em flagrante indica claramente uma associação havida entre todos eles para o preparo das drogas visando o tráfico, um colaborando na ação do outro, inclusive na mercancia no assentamento, pois segundo versão crível dos policiais, a própria droga encontrada com os adquirentes usuários era embalada de forma idêntica aquelas encontradas no interior do imóvel, indicativo de que havia sido comercializada há bem pouco. Assim, evidenciada a associação para o tráfico e também o delito do artigo 33 da lei de prevenção e repressão às drogas, pois que todos os réus, aliados à adolescente Jeniffer, estavam a atuar no depósito, guarda e preparo das substâncias entorpecentes, bem como no comércio clandestino de drogas. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se os acusados nos exatos termos da denúncia, em concurso material de delitos. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor ao tráfico, haja vista a incidência do delito associação ao tráfico em concurso material, devendo, outrossim, ser a pena base fixada acima do patamar mínimo, a se considerar a elevada potencialidade lesiva da condutas atribuída aos réus, que moviam o

preparo de elevada quantidade de entorpecente e de várias naturezas, que seguramente seria destinado ao abastecimento do tráfico local e à distribuição em larga escala. Na mesma toada e por iguais razões, de rigor seja fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra à Defensoria Pública, foi dito: MM. Juiz. A Defensoria Pública atua em prol do acusado Francisco, o qual, em conjunto com os demais corréus, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e no art.35, ambos c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Ocorre que, a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I- DA NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR: No caso dos autos, verifica-se que os policiais invadiram a residência do corréu sem a sua autorização e sem mandado de busca e apreensão domiciliar, apenas pelo fato de terem visto um sujeito correndo para dentro ao avistar a viatura. De acordo com a prova produzida, os policiais estavam realizando patrulhamento nas proximidades da residência do corréu, quando teriam passado em frente ao local e um sujeito (que, de acordo com os policiais, era o corréu Daniel), após ter avistado a viatura, teria corrido para dentro e gritado "polícia". Por esta razão, adentraram no local, sendo que ali teriam surpreendido todos os réus e teriam localizado os entorpecentes. Verifica-se que o argumento de o tráfico ser crime permanente não se aplica ao caso. Ademais, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores, o simples fato de a pessoa correr em direção à uma residência não justifica a entrada dos milicianos no local. O ingresso forçado em domicílio somente é legítimo, sem mandado judicial, desde que amparadas de fundadas razões, as quais devem ser devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso em concreto (artigo 240, §1º do CPP). Repise-se que o simples fato de o corréu, ao avistar a viatura policial, ter se esvaído em direção à residência, não é uma justificativa suficiente para o ingresso forçado e não configura a necessária "fundada razão". Como podemos ver, num caso bem semelhante aos fatos em comento, o STJ decidiu: "Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.681 - RS (2015/0307602-3) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Logo, não

se pode admitir que a simples constatação de situação de flagrante, após o ingresso, justifique a medida. Não seria coerente atribuir a um agente da segurança pública total arbitrariedade para, a partir da mera capacidade intuitiva, adentrar sem autorização, de maneira forçada na residência alheia. No caso em comento, a busca domiciliar, segundo os elementos colhidos na fase policial e judicial, ocorreu sem a prévia constatação da existência de flagrante delito. A subsequente (e sempre eventual) apreensão efetiva de drogas não tem o condão de suprimir a ilicitude que lhe antecedeu. Desta forma, o encontro e a consequente apreensão das drogas são ilegais em sua origem, diante da manifesta violação da garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Constituição Federal. II- DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Isso porque, não há nada de concreto que ligue o acusado às substâncias localizadas na residência. Desde o primeiro momento que foi ouvido, Francisco narrou que foi até o local para ver um jogo de rodas que Rafael estava vendendo e que viu Rafael, Rodrigo e Jeniffer mexendo nas drogas, mas negou qualquer participação no tráfico de drogas. Aliás, conforme se vê do documento de

fls. 359, o réu possuía ocupação lícita e trabalhava todos os dias na empresa Seara Alimentos, o que demonstra que sequer teria motivos e até condições para praticar o tráfico de drogas (já que trabalhava durante a noite). Tanto em solo policial quanto em juízo, o réu apresentou a mesma versão, afirmando que foi até a casa de Rafael para ver umas rodas que ele estava vendendo. Declarou não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Como se não bastasse as circunstâncias da abordagem não ficaram muito bem esclarecidas, já que a conduta do réu sequer foi individualizada. Ele foi preso tão somente por estar dentro da residência, não havendo nada que o vincule à residência invadida, aos entorpecentes e nem aos demais corréus. O policial Jonathan Lima narrou, em solo policial, que “patrulhavam pelo Bairro do Moquen, nesta cidade, nas imediações do Assentamento 23 de maio, numa estrada vicinal, quando, após abordarem dois indivíduos detidos por posse de drogas para consumo pessoal, fato isolado e registrado no termo circunstanciado n. EP 9075-1/2022 - DEL. SEC.ITAPETININGA, avistaram outro homem suspeito, saindo de uma residência próxima, o qual, ao ver a viatura policial, voltou correndo ao imóvel e gritou: “polícia”, para eventuais pessoas que se achavam no interior da casa, gerando fundadas suspeitas. Diante disso, o depoente e seu parceiro ingressaram neste imóvel, abrindo a porta, deparando-se com o rapaz que havia acabado de entrar, identificado como o ora autuado DANIEL FELICIANO DA SILVA e demais autuados RODRIGO PEREIRA SALES, FRANCISCO ERISVAN PEREIRA GONÇALVES, RAFAEL PEREIRA SALES e a adolescente infratora JENIFFER APARECIDA DA SILVA, todos na cozinha, envolta de uma mesa, preparando e embalando cápsulas eppendorf com cocaína, momento em que o flagranteado RODRIGO PEREIRA correu ao banheiro, conseguindo dispensar, no vaso sanitário, certa quantidade de cocaína, que estava num prato de cozinha, o qual foi apreendido com resquícios do pó branco. A seguir, na citada mesa da cozinha, o depoente e seu colega de equipe apreenderam 20(vinte) cápsulas de cocaína, 69(sessenta e nove) invólucros de crack e 01(uma) porção maior de crack, além do valor de R\$ 441,00 em notas variadas, 02(duas) balanças, centenas de cápsulas e embalagens plásticas vazias, mais 03(três) aparelhos celulares, 02 estiletes, ambos com resquícios de cocaína e 01(um) caderno com anotações, possivelmente, do tráfico. Prosseguindo com as buscas, no armário da cozinha, encontraram 12(doze) tabletes de maconha, envoltos em plástico roxo. E, por fim, na pia, localizaram 01(um) liquidificador com resquícios de cocaína e 01(uma) faca com resquícios de maconha. Indagados acerca dos fatos, das substâncias ilícitas e dos objetos, o autuado RAFAEL PEREIRA SALES se apresentou como o morador da residência, porém, como os demais imputados, negaram a propriedade das substâncias ilícitas, exceto a adolescente JENIFFER APARECIDA que apenas assumiu a posse de todas as drogas e objetos apreendidos”. Em juízo, voltou a dizer que viu dois indivíduos suspeitos na posse de drogas, próximos à residência e, no momento da abordagem, um indivíduo saiu da casa e voltou para dentro e gritou “polícia”, motivo pelo qual optaram por adentrar no local. Ali, estavam todos em volta de uma mesa que tinha drogas. Rodrigo teria se evadido em direção ao banheiro. Posteriormente, encontraram drogas também no vaso sanitário. Disse que a residência era de Rafael, porque ele afirmou que a casa era dele. Os usuários que foram apreendidos pela posse de droga não indicaram de quem haviam comprado as drogas. Ainda, disse que os indivíduos estavam dentro da residência, em volta da mesa, sentados, conversando e fumando. A menor, Jeniffer, assumiu a propriedade das drogas. Informou que nunca teve informações acerca da venda de drogas naquele imóvel. Nunca abordou Francisco anteriormente. Vê-se, portanto, que os policiais não viram qualquer ato de mercancia, não viram o acusado em contato com qualquer pessoa e, ainda, não apreenderam em seu poder qualquer apetrecho para o tráfico. Na verdade, ele está sendo processado tão somente por estar dentro do imóvel e, conforme predito, sua conduta sequer foi individualizada. Por outro lado, no local teria sido apreendido celular e anotações para o tráfico, os quais poderiam ter sido periciados a fim dar suporte a acusação, o que também não foi feito, não havendo qualquer informação acerca da vinculação do réu com referidas anotações para o tráfico ou, ainda, mensagens ou ligações no celular que indicassem a prática ilícita. Assim, havendo dúvidas acerca da prática delitiva, o que atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. III- DO

DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PERMANÊNCIA ESTABILIDADE. O delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não restou minimamente configurado no caso. Não há, nos autos, qualquer indício no sentido de que os réus teriam se associado para o cometimento do tráfico de drogas. A acusação não foi precedida de investigações que comprovassem o elo subjetivo entre eles ou entre algum deles. Aliás, o próprio policial ouvido relatou que não houve investigação prévia e que não houve nenhuma campana, além de que afirmou nunca ter abordado os réus juntos anteriormente. Além disso, apesar de terem sido apreendidas anotações e celular no dia do ocorrido, nenhum desses objetos foi periciado, não havendo qualquer indício de vinculação entre os réus. De outra parte, posto que se considere que os réus teriam, em unidade de desígnios, cometido o tráfico, não há nos autos qualquer prova ou indício de que cometessem a empreitada criminosa de forma habitual, sendo que é inerente ao tipo (art. 35 da Lei de Drogas) tal associação, não bastando o simples "ajuntamento eventual". Ou seja, associar-se significa unir-se de maneira estável com a finalidade de praticar diversos crimes. A característica da associação é a permanência e a estabilidade do vínculo. Há a necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O STF decide em consonância com o sobredito, vejamos: "A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes, dispensa o elemento mais característica das figuras penais de associação para delinquir, qual seja, a predisposição da *societas sceleris* à prática de um número indeterminado de crimes: para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama a sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada." (STF, RHC 75236/AM, 1ª Turma, Rel. Sepúlveda Pertence, DJU 01.08.1997). No que toca ao delito de associação, a conduta expressa no artigo exige permanência, o que definitivamente não houve no caso em tela. Em harmonia com esse entendimento, confira-se o posicionamento judicioso dos respeitadores doutrinadores Guilherme Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller: "O mero planejamento para uma eventual conduta de tráfico em conjunto fica evidentemente absorvido pelo próprio crime de tráfico, que exaure o potencial lesivo do planejamento, sem merecer relevância penal autônoma. Como não é possível crime sem lesão ou risco ao bem jurídico, a única interpretação viável e constitucional do artigo é que, para a tipificação da conduta, persiste sendo necessário a finalidade e permanência, como no crime de quadrilha do Código Penal, diferenciando-se daquela figura pelo elemento subjetivo (não basta querer praticar qualquer crime, mas apenas os previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 da Lei de Drogas) e pelo número de agentes (para o Código Penal, um mínimo de quatro, enquanto na Lei de Drogas são suficientes dois)". Diante do exposto, não tendo sido comprovada a associação estável e em virtude do respeito ao princípio in dubio pro reo, é imperiosa a absolvição dos acusados no que tange ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. IV- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Na hipótese vertente, afastado

o art. 35 da Lei n. 11343/06, caso entenda-se que o acusado praticou o crime previsto no art. 33, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas

formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida". (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. V- TESES SUBSIDIÁRIAS: Subsidiariamente, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja fixado o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos da tese exposta no item IV e, em caráter subsidiário, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, "b", § 3º, do CP, bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ; (iii) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das cautelares arroladas no art. 319 do CPP.

*Dada a palavra ao Dr. Vítor, foi dito: Meritíssimo Juiz: a pretensão do Ministério Público se mostra desprovida de guarida. A instrução processual demonstrou que Daniel jamais praticou qualquer um dos fatos narrados pela denúncia, inexistindo elementos de convicção sob o crivo do contraditório. Restou comprovado que Daniel é usuário e que esteve no local para adquirir entorpecente para uso próprio, impendendo seja desclassificada a acusação para a do artigo 28 da Lei Federal 11.343/06, inexistindo prova de qualquer ato que demonstrasse eventual comercialização ou associação pelo réu. Restou comprovado que se trata de usuário. Conforme se verifica pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, inexistente prova de dolo na conduta do réu. Inexiste qualquer prova de que o entorpecente localizado pelos policiais fosse de Daniel ou de que tivesse praticado qualquer ato de associação para o tráfico, inexistindo nexo de causalidade entre a acusação e sua pessoa. Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça já decidiu: TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO. Tráfico de Entorpecentes - Materialidade do crime e autoria delitiva - Prova insuficiente - Absolvição - Recurso improvido. Diante da insuficiência de provas da materialidade do crime e da autoria delitiva do cometimento de tráfico de entorpecentes, era de rigor a absolvição dos acusados. (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal; ACr nº 993.06.062836-4-São Paulo-SP; Rel. Des. Willian Campos; j. 1º/6/2010; v.u.). No caso em apreço, o conjunto probatório demonstrou que ele jamais comercializou entorpecente, bem como que a versão dos policiais não comprova nenhum dos tipos do artigo 33, inexistindo elementos para uma condenação, impendendo a lembrança de Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Inquérito Policial não são provas de materialidade. Ausente restou prova de eventual comercialização, inexistindo qualquer prova de que tivesse o réu eventualmente praticado qualquer ato de tráfico. Nada obstante, impende, ainda, a lembrança de que nossa sistemática não contempla a responsabilidade penal objetiva, assim como que elementos inquisitoriais são inábeis para o sustento de um decreto condenatório, pois, como é cediço, na fase inquisitorial não dispõe o acusado da devida oportunidade de defesa, tratando-se de elementos afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa constituindo-se os prejuízos daí advindos como presumíveis e inafastáveis. Cediço que para uma condenação criminal inadmissível se

mostra mera suposição, prova contraditória ou insegura, face o gravame que ocasiona na vida do condenado. Ainda, a de que no processo penal o ônus probatório está voltado exclusivamente ao Ministério Público, órgão encarregado da acusação, pois a única presunção admitida é a de inocência, ou seja, uma condenação somente pode emergir quando a prova se mostrar segura, incontroversa e apta a afastar todas as dúvidas. Do contrário, necessariamente a Ação Penal deve ensejar um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado Princípio In Dubio Pro Reo. Portanto, de rigor a total improcedência da Ação, pois a transparência da verdade real se mostra de extrema importância em processo penal, verificando-se pelas provas coligidas sob o crivo do contraditório a insuficiência de elementos que pudessem conduzir à autoria e à materialidade do que imputado pela denúncia, imperiosa se mostrando a absolvição, não se podendo fazer tabula rasa do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que ficam desde já prequestionados para os devidos fins de direito. DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - Como cediço, no Direito Penal a condenação somente tem lugar quando restar caracterizada, estreme de dúvida, a autoria e a culpabilidade do réu, não havendo sentido no surgimento de decreto condenatório sem a devida checagem de quem se trataria. Nesse sentido, situam-se os precedentes do TJ/SP e do Superior Tribunal de Justiça: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. - O Direito penal, porque regula o jus puniendi do Estado, rege-se por princípios que consubstanciam garantias constitucionais, para conter abusos contra o direito de liberdade, cuja proteção situa-se em plano universal. - Dentre os princípios constitucionais-penais merecem destaque o contraditório, o devido processo legal e ampla defesa, os quais vedam que alguém seja condenado com base em prova exclusivamente produzidas na fase do inquérito policial. - Não tem validade a sentença condenatória baseada apenas em provas produzidas na fase do inquérito, sendo uniforme o pensamento de que as provas requeridas nessa fase devem ser ratificadas em Juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. - Recurso ordinário provido. (RHC 10456/GO 2000/0092060-6 - Sexta Turma - Rel. Min. Vicente Leal - v.u - j. 20/09/01 - DJ 15.10.2001 p. 299)". Isto posto, postula-se pela total IMPROCEDÊNCIA da presente Ação para fins de que seja absolvido o acusado, nos termos do artigo 386, III ou senão VII, do Código de Processo Penal, ou senão que seja desclassificação a acusação a do artigo 28 da Lei 11.343/06, para que se faça a mais lúdima JUSTIÇA in specie. Dada a palavra ao Dr. Vinicius, foi dito: M.M. Juiz de Direito, a defesa dos acusados (Rodrigo e Rafael) roga para que seja julgada parcialmente a acusação, como segue: Inicialmente, Excelência, de todo o apanhado probatório processual, verifica-se que RAFAEL ASSUMIU TODA A PROPRIEDADE DA DROGA, INCLUSIVE AFIRMANDO QUE SEU IRMÃO (RODRIGO) SABIA DE TAL FATO E, INCLUSIVE, ACONSELHOU A NÃO PRATICAR TAL ATO. No mais, diante de tais afirmações, verifica-se que Rodrigo não tem nenhuma responsabilidade para com a droga apreendida, motivo pelo qual roga pela improcedência total da ação, ou seja, roga para que seja absolvido no Art.33 e 35 da Lei Antidroga. Em relação ao Policial Militar, o mesmo somente afirmou que viu 05 pessoas dentro da casa, mas de nada afirmou no tocante ao trafico, motivo pelo qual seu depoimento foi completamente vago. por fim, em relação ao Acusado Rafael, roga para que seja julgado parcialmente a denuncia, no sentido de absolve-lo no crime previsto no Art.35 e que seja condenado no Art. 33 da mesma Lei, bem como seja reconhecido o trafico privilegiado, ante os seus bons antecedentes, bem como sua confissão. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. DANIEL FELICIANO DA SILVA, FRANCISCO ERISVAN PEREIRA GONÇALVES, RAFAEL PEREIRA SALES e RODRIGO PEREIRA SALES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. De acordo com a denúncia, em dia, horário e lugar incertos, em data anterior ao dia 06 de agosto de 2022, nesta Cidade e Comarca, associaram-se, juntamente com a adolescente Jeniffer Aparecida da Silva, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Em 06 de agosto de 2022, por volta das 18 h e 45 min, na Rodovia SP 268, 100, Assentamento 23 de maio, Bairro Tupi, nesta Cidade e Comarca, os réus,

juntamente com a adolescente Jeniffer Aparecida da Silva, agindo em concurso e com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam, mantinham em depósito e traziam consigo, para fins de comércio, vinte microtubos contendo “cocaína”, com peso de 3,71 gramas; doze porções de “maconha”, com peso de 566,62 gramas; e setenta pedras de “crack”, com peso de 19,60 gramas; todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O Dr, Defensor do Acusado Daniel Feliciano apresentou defesa e requereu a liberdade provisória, fls. 263/270, o MP manifestou-se, fls. 274/275, e o pedido foi indeferido, fls. 276/277. Os Réus foram notificados, 285 – Rodrigo Pereira, fls. 287 – Francisco Erisvan, fls. 289 – Rafael Pereira e fls. 291 – Daniel Feliciano. Os Réus Francisco Erisvan, Rafael Pereira e Rodrigo Pereira apresentaram defesa preliminar, fls. 295/296. A denúncia foi recebida, fls. 297/298 e os Réus, citados, fls. 332 – Daniel Feliciano, fls. 334 – Rafael Pereira, fls. 336 – Francisco Erisvan e fls. 338 – Rodrigo Pereira. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos Réus (audiência por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação dos Réus nos exatos termos da denúncia; por outro lado, os Drs. Defensores insistiram na absolvição, exceto em relação ao Réu Rafael, para quem o Defensor pediu a aplicação de benefícios. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Analiso a prova coligida. Às fls. 25/26 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um celular, marca Samsung, modelo A25; um celular, marca Motorola;; um prato de vidro contendo resquícios de cocaína; um liquidificador, marca Mondial contendo resquícios de cocaína; uma faca; dois estiletes; um caderno de anotações; duas balanças de precisão; um saco contendo microtubos; um saco contendo diversas embalagens ZipLock; R\$ 441,00; um ZipLock contendo 69 pedras de “crack”; um ZipLock contendo uma pedra de “crack”; 20 porções de cocaína, com peso de 17,25 gramas; 11 tijolos inteiros e um quebrado de maconha, com peso de 576,75 gramas. Às fls. 238/243 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo em Entorpecentes n. 249.685/2022 no qual consignou: Item 1 “Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações

posteriores”. Item 2 “Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores”. Item 3 Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores”. Jonathan de Oliveira Lima, policial militar, testemunha, disse que estava em patrulhamento, quando viu duas pessoas próximas à casa, fizeram a abordagem, e, com elas, houve apreensão de drogas. Em certo momento alguém saiu da casa, viu os policiais, e retornou para o interior, tendo avisado que a polícia estava do lado de fora. Nestes termos os policiais entraram na casa e viram os réus e a adolescente, todos sentados ao redor da mesa, em cima da qual havia drogas. Os policiais localizaram liquidificador com resquícios, faca com resquícios, saquinhos, balança e caderno com anotações. Rodrigo, ao perceber a entrada dos policiais, foi ao banheiro com algo, e, posteriormente, lá os policiais localizaram um prato com resquícios de drogas, que tinham sido jogadas no vaso por Rodrigo. Paloma Aparecida de Meira, Testemunha, disse que Daniel é usuário de entorpecentes. Leandro Ribeiro Ramos, Testemunha, disse que o Réu Daniel é usuário de entorpecentes. Emerson Paulo Benedito Aparecido de Meira, Testemunha, disse que o Réu é usuário de entorpecentes. Rafael Pereira Sales, Réu, ao ser interrogado, disse que a droga lhe pertencia e era destinada à venda. Estava em dificuldades financeiras. Francisco foi levado à sua casa por Daniel para ver uma roda, mas acabou ficando e comprou entorpecente. Rodrigo é seu irmão e foi à casa para ver um motor de arranque. Ao perceber a entrada dos policiais, levantou-se e despejou parte das drogas no vaso sanitário. Francisco Erisvan Pereira Gonçalves, Réu, ao ser interrogado, disse que foi à casa para ver um aro, mas havia drogas e os

policiais chegaram. Rodrigo Pereira Sales, Réu, ao ser interrogado, disse que é irmão de Rafael e o tinha aconselhado a não vender drogas, a dificuldade financeira deveria ser superada por outra forma. Daniel Feliciano da Silva, Réu, ao ser interrogado, disse que foi à casa de Rafael para levar o Réu Francisco; em certo momento saiu da casa, viu os policiais, assustou-se e avisou os demais. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe porque os policiais, em patrulhamento, depararam-se com duas pessoas, as quais foram abordadas, todavia uma pessoa saiu do interior do imóvel, viu os policiais, retornou e avisou os demais, que foram surpreendidos pelos policiais no momento em que todos estavam ao redor da mesa; em certo momento, Rafael saiu e jogou parte das drogas no vaso sanitário. Em que pese a Testemunha Jonathan ter afirmado que Rodrigo teria ido ao banheiro, fato é que Rafael e Rodrigo são irmãos e a testemunha não conhecia ambos, então pode ter se confundido. Ora, a casa era do Réu Rafael, o qual confessou a propriedade de todos os entorpecentes e a finalidade mercantil. Havia a presença dos demais acusados e da adolescente na casa, porém há dúvidas se estavam envolvidos no comércio ilícito, já que, apesar da presença física no imóvel, circunstância comprometedora, inexistem outros elementos aptos a evidenciar o liame entre os réus e a adolescente e de todos eles com os entorpecentes. Nestes termos, surge a dúvida invencível que, no processo penal, resolve-se em favor da defesa, por aplicação do princípio in dubio reo, e impõe o reconhecimento do non liquet, com a absolvição dos Réus. Isto posto, de rigor a absolvição dos Acusados com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado, em relação ao Réu Rafael, além do imóvel ser sua morada, lá houve apreensão de drogas e ele próprio admite o comércio ilícito, e outra conclusão não se chega após a análise da quantidade e diversidade de drogas e da existência de apetrechos próprios do tráfico de entorpecentes e de contabilidade. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu Rafael mantinha em depósito substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu confessou, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em

1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar RAFAEL PEREIRA SALES, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006. Absolvo-o da acusação de incidir no art. 35, da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Absolvo DANIEL FELICIANO DA SILVA, FRANCISCO ERISVAN PEREIRA GONÇALVES, RAFAEL PEREIRA SALES e RODRIGO PEREIRA SALES, qualificados nos autos, da acusação de incidirem nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,

c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Substituo a pena privativa de liberdade do Réu Rafael pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar o Réu Rafael nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu Rafael respondeu preso ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em relação a todos os réus. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 18 de outubro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA